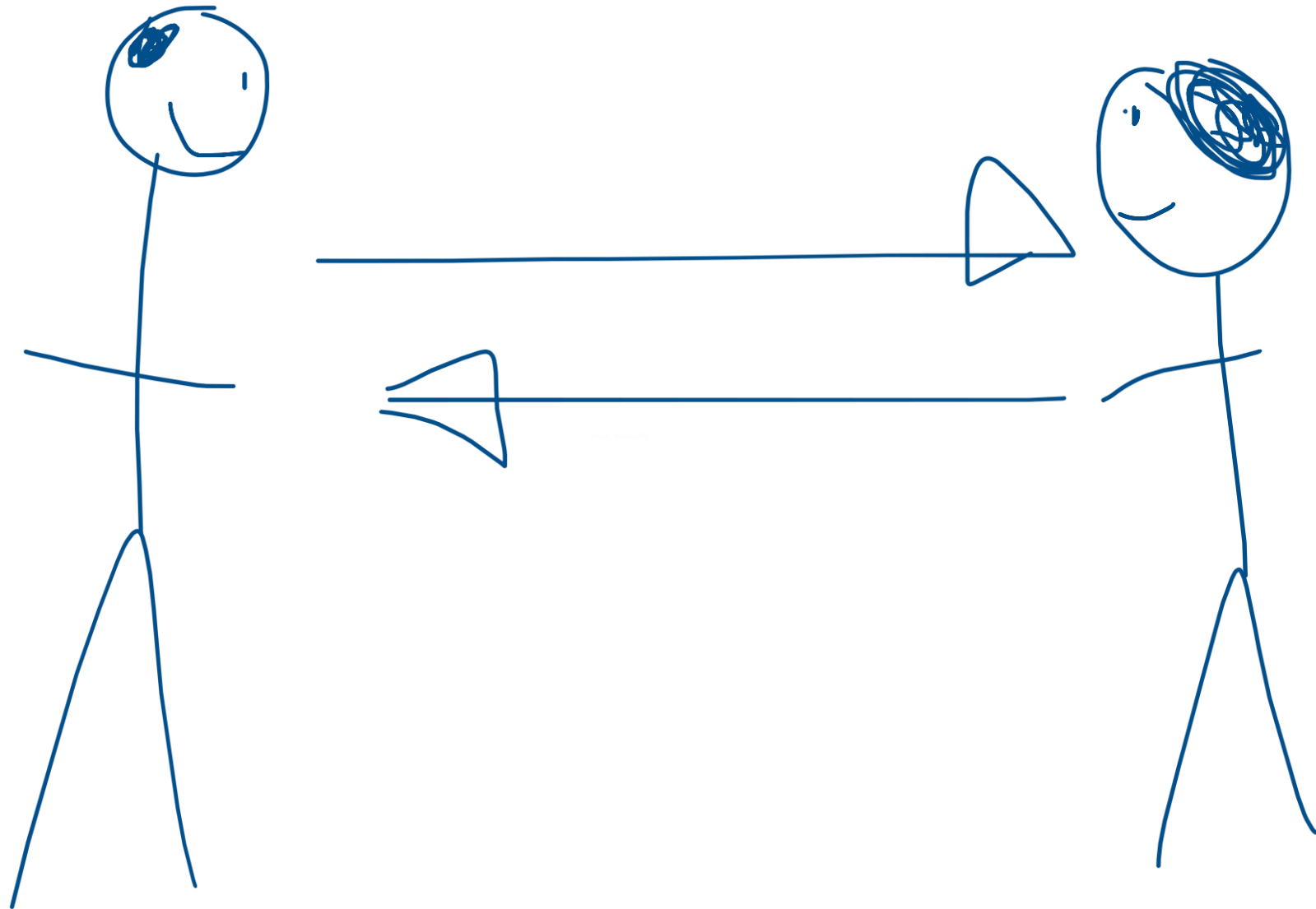




Grundsätzliches zum Vertragsrecht (kurzes Warm up)

Art. 19 OR

- 1 Der **Inhalt des Vertrages** kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
- 2 Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
 - Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Privatautonomie aber Einschränkung der Vertragsfreiheit durch zwingende Normen
 - Lückenfüllung durch dispositive Bestimmungen

Art. 1 OR

- 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die **übereinstimmende gegenseitige** Willensäusserung der Parteien erforderlich.
- 2 Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
 - Natürlicher Konsens = Einigkeit betreffend essentialia negotii (unentbehrliche Vertragspunkte)
 - Normativer Konsens = Kein übereinstimmender Wille, jedoch übereinstimmende Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip (versteckter Dissens)
 - Objektiv wesentliche Vertragspunkte = unentbehrliche Vertragspunkte
 - Subjektiv wesentliche Vertragspunkte = betreffen Vertragspunkte, ohne die eine Vertragspartei keinen Vertrag eingehen würde.

Grundsätzliches zum Vertragsrecht (kurzes Warm up)

Art. 2 OR

1 Haben sich die Parteien über **alle wesentlichen Punkte** geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.

- Beim Kaufvertrag: Kaufsache, Name der Parteien, Preis,
- Bei der Miete: Mietgegenstand, Höhe der Miete, Mietparteien
- Bei Innominatverträgen: Die wesentlichen Punkte müssen soweit vorhanden sein, dass der Sinn des Vertrages festgestellt werden kann.

Art. 11 OR

1 Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt.

- Keine Formvorschriften bei IT-Verträgen

IT-Verträge (Eigenschaften)

- **IT-Verträge** gehören zum betrieblichen Alltag. Sie zählen zu den Innominatverträgen und enthalten oftmals Elemente des Auftrags und/oder des Werkvertrages oder auch von anderen Vertragstypen, wie bspw. der Miete, Hinterlegung, Pacht oder dem Kauf.
- Die Abgrenzung ist oft schwierig und muss einzelfallspezifisch vorgenommen werden. **Umso wichtiger** ist es, im Vorfeld den Vertrag genau auf die Absichten der Parteien hin zu formulieren und auszulegen.

Hinterlegung: als was für einen Vertrag gilt es, z.B. Cloud als Mietvertrag. Miete ist unter Gebrauchsüberlassungsverträge.
Daten werden hinterlegt, Cloud Anbieter gibt Platz

IT-Verträge (Eigenschaften)

- Die Bestimmungen des OR kommen analog zur Anwendung. Umso wichtiger ist es, die einzelnen Elemente des Vertrages richtig zu subsumieren (Mängelrechte, Verjährung, Haftungsausschlüsse, Rügeobliegenheit etc.).
- Entwicklung einer App, Erstellung einer Website oder Entwicklung einer Individualsoftware, Installations- und Reparaturarbeiten = Erfolg ist i.d.R. geschuldet, daher überwiegend **Werkvertrag**
Werkvertrag = massgeschneidert für Kunden
es muss das einhalten
z.B. Massanzug
- Nutzungsrechte bei Cloudverträgen = Können Elemente der **Miete** enthalten
- Selbstständige Planung, Beratung und Projektmanagementleistungen = Das sorgfältige Tätigwerden ist im Vordergrund, daher überwiegend **Auftrag**
- Erwerb einer Standardsoftware: Die Regelungen betreffend den **Kaufvertrag** kommen analog zur Anwendung. Individuell konzipierte IT-Produkte haben aber **werkvertraglichen Charakter**.
- Wo die Bestimmungen des OR BT nicht oder nur beschränkt angewendet werden können, kommen die OR AT-Bestimmungen (z.B. Folgen der Nichterfüllung OR 97ff. oder Verjährung OR 127ff.) zum Tragen.

wenn die zwei firmen verschiedene AGBs haben, muss man beide AGBs vergleichen

IT-Verträge (Erscheinungsformen)

Einige **wichtige IT-Verträge**:

- Software-Lizenzvertrag: Einräumung von Rechten zum Gebrauch von Applikationen während längerer Dauer, gegen die Entrichtung von Benützungsgebühren. Bspw. unbefristete Lizenzierung, Abonnement-basierte Lizenzierung (Spotify, Adobe, Netflix), Netzwerklizenzen, Cloudbasierte Lizenzierung
- Wartungsvertrag: Vertragsgegenstand ist der Erhalt/Verbesserung und/oder die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Software oder die Aktualisierung, Beratung sowie Pflege der Software.
- Dienstleistungsvertrag für Planung und Beratung
- Lieferung von integrierten Informatiksystemen
- Systemintegrationsvertrag: Planung, Einrichtung und Aufbau von IT-Systemen. Prüfung von Kompatibilität von Hardware- und Softwarekomponenten
- IT-Werkvertrag: Es ist ein bestimmbares oder bestimmtes Ergebnis geschuldet. Das Werk muss genau, auch für Dritte nachvollziehbar, umschrieben und definiert werden.
- IT-Dienstleistungsvertrag: Der Beauftragte verpflichtet sich, für den Kunden in fachgerechter Sorgfalt tätig zu werden, nicht aber zur Realisierung eines bestimmten Erfolges.

IT-Verträge (Erscheinungsformen)

- Outsourcingvertrag: **Outside Resource Using**, Auslagerung von IT-Systemen oder Prozessen
- Software Escrow Agreement: Entwickler hinterlegt den Source Code von Software bei einem neutralen Dritten. Der Escrow-Agent bewahrt den Source Code sicher auf. Erst wenn eine der vordefinierten Voraussetzungen eintritt, gibt der Escrow-Agent dem Kunden den Source Code heraus.
- Cloud Services:
 - Infrastructure as a Service (IaaS) = Bereitstellung von Speicher, Netzwerk, Servern und Virtualisierung (Bspw. IBM Cloud, Google Compute Engine, Amazon Web Services und Microsoft Azure)
 - Software as a Service (SaaS) = Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d.h. als Service, angeboten werden. Die Nutzung erfolgt in der Regel auf Abonnementbasis. SaaS wird auf Remote-Servern betrieben und vom Anbieter verwaltet, aktualisiert und gewartet. (Bspw. Dropbox, Microsoft Office oder Google Apps)
 - Platform as a Service (PaaS) = Plattform kann über das Internet genutzt werden und bietet Nutzern sowohl ein Framework als auch passende Tools, um Applikationen und Software zu entwickeln. (Bspw. Windows Azure, SAP Cloud oder Google App Engine)

IT-Verträge (Erscheinungsformen)

- Hardwareverkaufsvertrag
- Softwareentwicklungsvertrag: Entwickler erstellt eine Software-Applikation nach den konkreten Vorgaben des Bestellers
- Roamingverträge: Nutzung des mobilen Endgerätes in einem ausländischen Netz für Telefonate, Nachrichten und mobile Daten
- Software-Distributionsvertrag: Hersteller oder Lieferant beauftragt einen Vertreiber mit dem Verkauf seiner Produkte
- Erbringung von Hosting-Dienstleistungen: Überlassung von Speicherplatz auf der Serverinfrastruktur des Anbieters für die Website oder Applikation des Kunden sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen.
- Konzeption und Realisierung einer Web-Applikation: Softwareprogramm, das auf einem Webserver ausgeführt wird. Im Gegensatz zu Desktop-Anwendungen, die lokal auf einem Computer installiert werden, muss auf Webanwendungen über einen Webbrowser zugegriffen werden. Bspw. Webshop oder Internet-Banking-Programme, Evernote, Google Apps, Pocket.
- Erstellen einer Website



Versuchen Sie die unterstrichenen Verträge einem möglichst passenden Nominatvertrag zuzuordnen.

Leistungsstörungen im Zusammenhang mit IT-Verträgen

Mögliche Leistungsstörungen sind:

- Das IT-System funktioniert nicht wie erwartet/zugesichert. Kaufvertrag, Dienstleistung/Beratung
- Softwarefehler führen zu Systemausfällen und Datenverlusten software gekauft oder gemischt mit installation : es kommt darauf an, software wurde gekauft ist abgeschlossen.
- Anfälligkeit des Systems auf Hackerangriffe Schadenersatz nicht unbedingt, haftung.
- Systemzugriffe sind nicht möglich wenn Software selber kaputt ist möglicherweise Kaufvertrag:Gewährleistung
- Prozesse laufen nicht wie vorgesehen ab Software = unmittelbarer Schaden, Schaden durch Software = mittelbarer Schaden

Konsequenzen können sein:

- Produktionsausfälle (Einnahmenverlust, Schadenersatzansprüche von Vertragspartnern, weitere mittelbare Schäden)
- Personenschäden bei Systemausfällen/Fehlsteuerung von sicherheitsrelevanter Software
- Reputationsschäden
- Persönlichkeits- und Datenschutzverletzungen

Mögliche Haftungsansprüche:

- Ausservertragliche Haftungsansprüche (z.B. Delikt- (OR 41), Geschäftsherren- (OR 55) und Produkthaftung (PrHG)) siehe notizen
- Vertragliche Haftungsansprüche (z.B. Arbeitsrechtliche Ansprüche (OR 321e), Gewährleistungs- und Haftungsansprüche (z.B. OR 97))
- Verantwortlichkeitsansprüche

IT-Verträge (Mängelrechte)

Bei Mängeln ist jeweils darauf zu achten, welche rechtlichen Grundlagen am ehesten zur Anwendung kommen, sofern die Parteien diesbezüglich nichts vereinbart haben:

- Mängel und Verzug bei:
 - **kaufvertraglichen** Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Kaufvertrag insb. Art. 197ff. OR (Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung)
 - **werkvertraglichen** Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Werkvertrag Art. 363ff. OR (Wandelung, Minderung oder Nachbesserung)
 - **auftragsrechtlichen** Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Auftrag Art. 394ff. OR (Schadenersatz)

Risiken/Probleme im Zusammenhang mit IT-Verträgen

Uneinigkeit betreffend der zu erbringenden Leistung

sauber formulieren,
was ist der Leistungsumfang

Mangelhafte Vertragserfüllung (Nichterfüllung/Schlechterfüllung)

Mängel klar, genau definieren

Haftung

wer haftet? welche Haftung? Begrenzte Haftung

Datenschutzverletzungen

Sich verändernde Bedürfnisse des Leistungsnachfragers

KI Tool

mach schnell

kunde wechselt etwas aus

compliance, risk,
security, business
stakeholder, Preise
procurement

Höhere Kosten als erwartet/veranschlagt

Ausschreibungsverfahren, Provider zu knapp kalkuliert

Preis wird während umsetzung geändert? in vertrag notieren!

Ausstehende Zahlungen

Vorzeitige Vertragsauflösung

IT-Verträge (Regelungspunkte in den Verträgen)

Folgende Punkte sind i.d.R. in IT-Verträgen relevant und sollten geregelt werden:

- **Genaue Umschreibung der vertraglichen Leistung:** Je präziser desto weniger Schwierigkeiten gibt es bei der Auslegung (Pflichtenheft, Termine und Mitwirkungspflichten der Parteien, usw.).
 - Sind alle Vertragsleistungen vollständig und klar festgehalten?
- **Preis:** Es ist sinnvoll den Preis und die darunterfallenden Leistungen möglichst klar zu definieren.
 - Preis definiert oder ohne Weiteres berechenbar (Stück, Stunde, Pauschale)? Preis für zusätzliche Leistungen resp. Preisanpassungsmechanismus auch bei ausserordentlichen Umständen (fehlende Vorhersehbarkeit und klares Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung) festgelegt?
Zwischenleistungen /(z.b. mvp) definieren, dass sie in gesetz eingebaut werden und dann vertrag anpassen möglich.
- **Nutzungsrechte:** Wenn bspw. die Nutzung von einem Dritten zur Verfügung gestellt wird (z.B. Microsoft365). Nutzungsrechte sind zeitlich limitiert und können nach Vertragsende nicht mehr weitergenutzt werden. Allfällige damit verbundene Migrationen können daher zu hohen Zusatzkosten führen.
Lizenz, Subprocess(?) können auch von provider von provider vorhanden sein. Lizenzrechte nicht verletzen
Lizenzverletzung: immaterialgüter, urheberrecht, patent
- **Lizenzverträge** (Innominatverträge sui generis): Inhaber eines Immaterialgüterrechts gewährt Nutzung gegen Entgelt.
 - Sind eigene Lizenzverträge oder von Dritten zu beachten?

IT-Verträge (Regelungspunkte in den Verträgen)

- **Regelungen den Datenschutz und die Informationssicherheit betreffend:** Werden bspw. Personendaten bearbeitet? Welchen Sicherheitsstandard hat der Provider?
- **Geheimhaltung:** Der Dienstleistungserbringer hat nicht selten Einblick in wichtige und geheim zu haltenden Geschäftsinformationen.
- **Gewährleistungsrecht und Haftung:** Für welche Leistung muss wer, wie einstehen?
 - Als Mangel wird in der Technik generell eine Abweichung von Vorgaben angesehen, während im rechtlichen Sinne ein Mangel ursächlich für eine **Beeinträchtigung der vertraglich geschuldeten Leistung** (subjektive- und objektive Wesentlichkeit) sein muss.
 - Mängel können sein: Schlechte Kostenschätzung oder Kostenkontrolle, mangelnde Benutzerfreundlichkeit, rechtliche Mängel (fehlende Lizenzen), notwendige Funktionen fehlen, Viren in der Software, keine ausreichende Performance, Drittkomponenten sind nicht kompatibel oder ganz allgemein, das Fehlen von zugesicherten Eigenschaften
 - Sind die Mangelanmeldeprozesse eindeutig definiert? Ist definiert, was Mangelbehebung und was ein kostenpflichtiger Support ist? Wer haftet und wie (beschränkt oder unbeschränkt)?
- **Vertragsauflösung:** Ordentliche- und ausserordentliche Auflösung

Mögliche Vertragsklauseln

• 7. Gewährleistung und Abnahme der Leistungen

- 7.1 Gewährleistung
 - 7.1.1. **Grundsatz:** Optiwork erbringt ihre Leistungen mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gewährleistet das zwischen den Parteien vereinbarte Funktionieren der Produkte und Dienstleistungen. Kleinere, die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch nicht erheblich mindernde oder aufhebende Fehler können allerdings nicht mit Sicherheit vermieden werden.
 - 7.1.2. **Für eigene Software:** Es gelten die Bestimmungen des Softwarelizenzvertrages DOMUS.
 - 7.1.3 **Für Hardware und Fremdsoftware:** Es gelten die **Garantiebestimmungen des Drittlieferanten.**
- 7.2 **Abnahme:** Die Abnahme erfolgt nach erbrachter Leistung. Ein Abnahmeprotokoll ist nur aufgrund einer speziellen, gegenseitigen Vereinbarung vorgesehen.
- 7.3 **Nach erfolgter Abnahme:** Für die Zeit nach der Abnahme schliessen die Vertragsparteien einen Wartungsvertrag ab.
- 7.4 **Mängelrüge:** Eine detaillierte Mängelrüge ist vom Kunden schriftlich während eines laufenden Projektes oder **spätestens 30 Tage** nach Erhalt einer Teil- oder Schlussrechnung an Optiwork zuzustellen.
Als Mängel verstehen die Vertragsparteien wesentliche Abweichungen von der Spezifikation gemäss Auftragsbestätigung, Vertrag oder des Programmbeschriebes, die den Wert oder die Tauglichkeit für den im Vertrag oder Auftrag vorgesehenen Gebrauch aufheben oder erheblich mindern.
- 7.5 **Kostenlose Mängelbehebung:** Optiwork behebt gerügte und **von Optiwork anerkannte Mängel** ohne Kostenfolge für den Kunden. Aufwendungen der Kunden werden nicht von BRZ übernommen.
- 7.6 **Kostenpflichtige Mängelbehebung:** Stellt sich nach gemeinsamer Prüfung durch beide Parteien heraus, dass ein gerügter Mangel nachweislich nicht durch Optiwork zu vertreten ist, so ist der Kunde verpflichtet, der **Optiwork die entstandenen Aufwendungen nach den jeweils gültigen Preisen und Bedingungen zu vergüten.**
- 7.7 **Weitergehende Ansprüche:** Andere Rechtsbehelfe als die Nachbesserung werden, vorbehältlich von Schadenersatz im Falle von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere ist der Kunde nicht berechtigt, die Nachbesserung selber vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen und die entsprechenden Kosten gegenüber Optiwork geltend zu machen.



Beurteilen Sie diese Klausel aus der Sicht des Bestellers. Was würden Sie ändern?

Mögliche Vertragsklauseln

8. Haftung

8.1 Voraussetzungen: Bei Vertragsverletzungen oder unerlaubten Handlungen, welche von Optiwork oder deren Mitarbeitenden zu verantworten sind, haftet Optiwork nur, soweit die Vertragsverletzung oder eine unerlaubte Handlung durch rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.

8.2 Begrenzung der Haftung: Sofern in den einzelnen Verträgen keine weitergehende Begrenzung der Haftung und der Schadenersatzpflicht vereinbart ist, wird die Höchstsumme des Schadenersatzes in jedem Fall auf die seitens des Kunden unter dem entsprechenden Einzelvertrag bereits geleisteten jährlichen Zahlungen oder geschuldeten Entgelte beschränkt. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche des Kunden im Fall der Kündigung des Vertrages oder des Rücktrittes vom Vertrag durch den Kunden.

8.3 Folgeschäden: Optiwork haftet auf keinen Fall für Mangelfolgeschäden, mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Frustrationsschäden oder Ansprüche Dritter, die an den Kunden gestellt werden.

8.4 Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen: Sämtliche Haftungs- und Gewährleistungsansprüche werden ausgeschlossen, wenn Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung von Optiwork Eingriffe an deren Produkten vornehmen oder wenn der Kunde ohne ausdrückliche Zustimmung von Optiwork Änderungen an der Hardware-Charakteristika, Installationen, Betriebssoftware oder anderer mit der Leistung von Optiwork im Zusammenhang stehenden Software vornimmt oder vornehmen lässt.

8.5 Unzureichende Mitwirkung des Kunden: Wenn der Mangel auf der vom Kunden gegebenen Aufgabenstellung oder der fehlerhaften und/oder unzureichenden Mitwirkung des Kunden beruht, werden alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

8.6 Verhinderung der Leistungserbringung: Wird Optiwork aus Gründen, welche sie nicht zu vertreten hat, an der zeitgerechten oder sachgemässen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag gehindert, so entsteht ebenfalls kein Haftungsanspruch.



Beurteilen Sie diese Klausel aus der Sicht des Bestellers. Was würden Sie ändern?

IT-Verträge (Erscheinungsformen)

- **Schauen Sie sich einmal eine der nachstehenden Vertragsgrundlagen in Ruhe an:**
 - Allgemeine Nutzungsbedingungen Spotify: [Allgemeine Nutzungsbedingungen – Spotify](#)
 - Allgemeine Nutzungsbedingungen Netflix: <https://help.netflix.com/legal/termsfuse>
 - Allgemeine Geschäftsbeziehungen SAP AG: [General Terms and Conditions | Agreements | SAP Trust Center](#)
- **und beurteilen Sie insbesondere die folgenden Punkte:**
 - **Haftung** kurz erwähnt, St. Vincent Karibische Insel als Gerichtsstand. ist ein sehr schlechtes Zeichen.
 - **Gerichtsstand** sollte beachtet werden bei AGB anschauen.
 - **Gewährleistung** zwingende Gerichtsstände: bei Lebensmittel z.B. dann nicht änderbar. Konsumentenrecht zwingend in der Schweiz.
 - **Datenschutz** zwischen 2 Unternehmen kann mehr frei der Gerichtsstand gewählt werden.
 - **Preisänderungen und Änderungen beim Leistungsumfang**



Gerichtsstand:
dort Klage einreichen
kann sehr teuer sein
anderes Gesetz

wiederholung, aber schon wichtig.

IT-Verträge (Mängelrechte)

Bei Mängeln ist jeweils darauf zu achten, welche rechtlichen Grundlagen am ehesten zur Anwendung kommen, z.B.:

- Bei Mängeln und Verzug bei kaufvertraglichen Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Kaufvertrag insb. Art. 197ff. OR (Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung)
- Bei Mängeln und Verzug bei werkvertraglichen Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Werkvertrag Art. 363ff. OR (Wandelung, Minderung oder Nachbesserung)
- Bei Mängeln und Verzug bei auftragsrechtlichen Eigenschaften s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Auftrag Art. 394ff. OR (Schadenersatz)